

1500072-58.2021.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Walter Emídio da Silva

Comarca: Guaratinguetá

Foro: Foro de Guaratinguetá

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 10/01/2022

... confirma que o acusado foi um dos autores do roubo.

Deve ser levado em conta as versões apresentadas pelas vítimas, que sequer conheciam os acusados.

Neste sentido:

"ROUBO - Palavra das vítimas - Valor Probante: 90(b) - Em delitos de roubo, de regra não testemunhados, as palavras das vítimas, se uniformes e coerentes, são elementos seguros de convencimento, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaratinguetá

Foro de Guaratinguetá

4ª Vara

Avenida Ariberto Pereira da Cunha, 280, Portal das Colinas - CEP 12516-410, Fone: (12) 3125-4133, Guaratinguetá-SP - E-mail: guarat4@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:

1500072-58.2021.8.26.0621 - Ação Penal - Procedimento Ordinário

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

VANDERLEY LUIZ PONCIANO e outros

CONCLUSÃO

Aos 06 de dezembro de 2021, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 4ª Vara, DR. WALTER EMÍDIO DA SILVA.

Eu, Walter Emídio da Silva, digitei.

Vistos.

VANDERLEY LUIZ PONCIANO qualificados nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do Artigo 157, § 2º, incisos II (concurso de pessoas), V (restrição de liberdade das vítimas) e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), na forma do artigo 70, concurso formal, por duas vezes (duas vítimas com patrimônios distintos), todos do Código Penal, porque o acusado, no dia 11 de janeiro de 2021, agindo em concurso e total adesão de vontades com um indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, subtraiu em proveito comum, uma pulseira de prata, um aparelho celular, marca Iphone, um relógio de pulso, marca G. Shok, e uma carteira contendo R\$107,00, pertencentes a Thiago César Abreu Florêncio, bem como um aparelho celular marca Sony e a quantia de R\$ 10,00, pertencentes a Rafael Pereira de Vasconcelos.

A denúncia veio devidamente instruída com Inquérito Policial de fls. 04/104.

Recebida a denúncia no dia 28 de abril de 2021 (fls. 133/134), o acusado foi citado

e apresentou a sua defesa preliminar a fls. 155/ 185.

Face a inexistência das causas previstas no Artigo 397 do CPP, foi mantido o recebimento da denúncia com consequente designação de audiência de instrução e julgamento (fl. 203).

Em audiência foi colhido o depoimento de uma das vítimas, tomadas as declarações de tres testemunhas do rol acusatório, duas testemunhas do rol defensivo e interrogado o réu.

Em alegações finais de fls. 242/254, o Dr. Promotor de Justiça postulou a procedência da ação penal, condenando-se o réu como incurso nas penas do Artigo 157, §2º, II e §2º - A, inciso I, cc o Artigo 70, por duas vezes, todos do Código Penal.

Por sua vez, a defesa do acusado em suas alegações finais de fls. 255/273, postulou a absolvição do acusado, sob a alegação de que a prova dos autos é dúbia e inconsistente para alicerçar um decreto condenatório.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal que tem por escopo a apuração de crimes previstos no Artigo 157, § 2º, incisos II (concurso de pessoas), V (restrição de liberdade das vítimas) e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), na forma do artigo 70, concurso formal, por duas vezes (duas vítimas com patrimônios distintos), todos do Código Penal.

A materialidade delitiva vem comprovada pelos autos de inquérito policial de fls. 04/104, onde se acham acostados o auto de prisão em flagrante de páginas 04/05, boletim de ocorrência (fls. 6/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), auto de entrega (fls. 17/18) e auto de avaliação (fls. 94/95).

Na fase policial (fls. 26), o acusado optou pelo silêncio.

Na fase Judicial, o acusado, ao ser interrogado, asseverou que "no dia dos fatos saiu para trabalhar. Salientou que ao passar próximo da rodoviária de Aparecida, dois rapazes deram sinal de parada. Aduziu que atendeu o sinal dos rapazes, que pediram para serem levados para Guaratinguetá. Disse que os dois rapazes eram morenos, altos e fortes. Aduziu que ao chegarem em Guaratinguetá, os rapazes pediram para dar três voltas no quarteirão. Salientou que os rapazes pediram para que ficasse esperando, pois voltariam para a cidade de Aparecida. Disse que cinco minutos após, eles voltaram e mandaram seguir para Aparecida. Aduziu que perto da Basílica, eles mandaram parar o carro, desceram e proferiram ameaças, dizendo que sabiam onde era a sua residência. Asseverou que chegando em casa, deixou o carro na rua e ingressou no imóvel, oportunidade em que narrou os fatos a sua esposa. Disse que cerca de vinte minutos após, bateram em seu portão. Narrou que eram policiais militares. Falou que permitiu que os policiais entrassem na sua residência. Narrou que os policiais revistaram a casa e não encontraram nada. Asseverou que antes de entrar em casa viu os celulares no assoalho do carro e os jogou fora, em um terreno ao lado. Relatou que os policiais encontraram um par de tênis na casa e os celulares no terreno ao lado da sua casa. Reclamou que ficou preso na viatura policial, por mais de uma hora. Informou que já foi processado em 1995, por posse de drogas. Salientou que seu veículo não tem identificação de Uber, possui apenas placa vermelha. Asseverou que trabalhava em aplicativo, mas não era inscrito. Não conseguiu explicar como tais indivíduos sabiam, que ele era motorista de aplicativo. Aduziu que não conhecia os indivíduos. Salientou que parou o carro na esquina. Relatou que ficou sozinho no carro a espera dos dois indivíduos. Salientou que viu uma arma nas mãos de um dos indivíduos. Disse que viu eles entrando em uma residência. Justificou que teve que ficar esperando porque tinha que receber a corrida e também porque tais indivíduos disseram que voltariam para Aparecida". A negativa do acusados não encontrou ressonância na prova amealhada para os autos. Senão vejamos.

A vítima Rafael Pereira Vasconcelos, ouvida sob o crivo do contraditório, "asseverou que, no dia dos fatos, estava na companhia de Tiago. Disse que foram até a casa do Sr. Jorge. Aduziu que iriam passar alguns dias no imóvel de Jorge, pois estavam com suspeita de COVID-19. Salientou que quando descarregavam os objetos

que estavam no carro, perceberam a passagem de um carro de cor branca. Aduziu que reparou no veículo, mas não percebeu nada de anormal. Relatou que, de repente, dois indivíduos invadiram a casa e anunciaram o assalto. Sustentou que o portão estava aberto e não houve tempo suficiente para ingressar na casa. Aduziu que foram amarrados e obrigados a se deitarem no chão. Disse que os assaltantes jogaram um cobertor encima deles. Relatou que os assaltantes invadiram a casa a procura de objetos de valor. Disse que não havia objetos de valor na casa. Afirmou que os assaltante queriam as chaves do carro e dos quartos. Salientou que, em dado momento, o sr. Jorge apareceu no local. Disse que escutou uma gritaria, oportunidade em que os assaltantes proferiam ameaças dizendo "vai embora ou a gente vai matar você". Afirmou que em dado momento houve um silêncio. Narrou que resolveu se levantar, pois a sua mão não estava bem amarrada. Asseverou que assim que conseguiu se desvencilhar, juntamente com a vítima Tiago, correu para dentro do imóvel e trancou as portas. Afirmou que percebeu que os assaltantes não estavam mais ali. Relatou que os assaltantes levaram os celulares, pulseira de prata e dinheiro em espécie. Narrou que os assaltantes queriam levar o carro, mas como o sr. Jorge apareceu os assaltantes desistiram. Confirmou que o réu foi preso em Aparecida. Afirmou que o acusado era o dono do veículo que viu passar antes de iniciado o assalto. Afirmou que não era Uber e o réu não tinha habilitação. Confirmou que os pertences foram encontrados dentro do veículo e os celulares na casa, no muro ao lado. Salientou que o policial militar rastreou o celular de Tiago, o que possibilitou o encontro dos objetos roubados. Aduziu que dentro do carro foram encontrados os objetos pertencentes a Tiago, suas pulseiras. Afirmou que não acompanhou as diligências em Aparecida. Sustentou que soube por intermédio dos policiais. Confirmou que os dois assaltantes portavam armas de fogo. Disse que não chegou a ver o rosto deles, pois estava tarde, escuro e os assaltantes estavam encapuzados. Concluiu que o roubo durou cerca de dez minutos. Disse que reconheceu o moletom e o tênis verde apreendidos. Salientou que os assaltantes pareciam jovens e magros. Acentuou que viu o veículo passando duas vezes na frente do local onde estava, por isso achou estranho. Disse acreditar que havia uma terceira pessoa esperando no carro para dar fuga, porque foi muito rápida a evasão. Salientou que havia cem reais na carteira de Tiago que não foi recuperado. Concluiu que o réu estava muito alterado na delegacia. Disse que um dos assaltantes era branco. Afirmou não lembrar da cor do outro assaltante. Relatou que um dos assaltantes tinha aproximadamente 1,65 metros de altura e outro cerca de 1,80 metros de altura. Disse que o sr. Jorge notou o carro estacionado nas imediações. Disse que o tênis tinha uma cor esverdeada, de mola, marca nike".

A vítima Tiago César Abreu Florêncio, ouvida na fase policial, corroborou a versão apresentada pela vítima Rafael (fls. 20), porquanto asseverou que "chegava na residência do sr. Jorge, que fica na Rua Sargento Baracho n.177, na Vila Paraíba, cidade de Guaratinguetá, na companhia de Rafael, oportunidade em que guardavam as coisas do veículo e colocavam no interior da residência, viu dois indivíduos em companhia de Rafael, sendo que um deles portava uma arma de fogo, tipo revólver, ambos de cor parda e magros, sendo que um deles era alto e o outro um pouco mais baixo e trajavam blusa de moletom, sendo que um deles tinha o moletom de cor azul e branco e o outro blusa de moletom preta. Disse que eles invadiram a casa e determinaram que deitassem no chão. Afirmou que nesse momento eles amarraram a suas mãos com fita plástica adesiva tipo "durex" e os cobriram com uma manta. Aduziu que conseguiu ver que um dos ladrões calçava um tênis azul. Salientou que ato continuo eles passaram a exigir dinheiro, mas como não havia dinheiro em espécie na casa, eles revistaram o declarante e seu colega, oportunidade em que subtraíram de Rafael, seu aparelho celular, a chave de seu veículo e a importância de R\$ 10,00 (dez reais) e do declarante foi furtado o seu aparelho celular, marca Iphone, um relógio de pulso, pulseira de prata, sua carteira contendo seus documentos pessoais e a importância de R\$ 107,00 (cento e sete reais). Em seguida passaram a revistar a casa toda, neste interim, Jorge, proprietário da casa, chegou e foi ameaçado pelos roubaores que o advertiram de que se tratava de um assalto e o mandaram embora. Que durante algum tempo, não ouvido mais movimentações saiu da casa correndo em companhia de Rafael, oportunidade em que pediu ajuda a um motociclista que por ali

passava e com o telefone celular desta pessoa acionaram a polícia militar. Enquanto um policial militar registrava a ocorrência, o declarante forneceu aos policiais o seu e-mail e sua senha, para que houve a localização do aparelho. Uma vez que foi comunicado pelos policiais da localização do veículo GM-Spin de cor branca, deslocou-se a esta repartição policial, onde não reconheceu o indivíduo aqui detido, porém Rafael reconheceu seu Aparelho celular e o declarante seu aparelho celular da marca Iphone, sua carteira, seu relógio de pulso e uma pulseirinha de prata. Aduz em suas declarações que nesta repartição reconhece o par de tênis de cor azul, ora apreendido como sendo o mesmo calçado utilizado por um dos ladrões, bem, como a blusa de moletom de cor azul e branca. Aduz em suas declarações que não experimento ferimentos em razão dos fatos ora narrados".

O policial militar Geraldo Arantes Carvalho de Miranda, ouvido sob o crivo do contraditório, asseverou que "no dia dos fatos, estava de serviço em Aparecida, quando recebeu, via rádio, a notícia de um roubo em Guaratinguetá. Disse que as viaturas se dirigiram ao local do fato. Aduziu que obtiveram informações de que os assaltantes teriam usado um veículo Spin, cor branca. Asseverou que uma dos celulares roubados era um IPHONE. Afirmou que fizeram o rastreamento do referido celular. Relatou que foi possível apurar a localização na cidade de Aparecida. Afirmou que ao chegar no local, já divisou o veículo Spin, cor branca, com placas de São Paulo. Disse que foi realizada a consulta no sistema "detecta" de Guaratinguetá, que apontou a entrada desse veículo na cidade de Guaratinguetá no horário aproximado do roubo. Asseverou que o celular da vítima foi localizado. Disse que foi feito contato com uma senhora moradora do imóvel. Disse que essa senhora atendeu do segundo andar do imóvel. Afirmou que o réu levou quase uma hora para atender os policiais. Disse que o imóvel dava acesso para os dois lados. Aduziu que após conversar com o réu e explicar o que estava acontecendo ele deu acesso ao imóvel. Salientou que os policiais direcionaram suas ações para encontrar o Iphone. Relatou que dentro da residência, a vítima, proprietária do celular, acionou o alarme de "pânico", o que permitiu localizar o celular do lado de fora, ao lado do muro da residência. Afirmou que foi localizado o Iphone e uma carteira. Sustentou que foi realizada uma vistoria na casa, oportunidade em que foi encontrado um par de tênis Azul e um celular de marca Sony. Relatou que o tênis encontrado tinha sido mencionado pelas vítimas. Sustentou que o acusado disse que era taxista e dono do Spin branco, que estava estacionado a cinquenta metros do local. Aduziu que no interior do Spin branco foram encontrados uma corrente de prata e um relógio. Afirmou que tais objetos e o tênis foram prontamente reconhecidos pelas vítimas. Confirmou que em vistoria mais detalhada no veículo, foi encontrada uma blusa de moletom, que foi reconhecida por uma das vítimas. Disse que, diante dos fatos, o réu foi preso e autuado em flagrante".

A roborar a versão apresentada pelo policial militar Geraldo Arantes Carvalho de Miranda, esta o depoimento de seu colega de farda Vagner da Fonseca, que ouvido sob o crivo do contraditório, asseverou "no dia dos fatos recebeu todas as informações do COPOM. Salientou que permaneceu na divisa da cidade. Disse que obteve informações sobre o paradeiro do Iphone. Afirmou que se dirigiram para o local e lá localizaram o veículo Spin branco, que teria sido usado pelo acusado no roubo. Disse que o Iphone estava a trinta ou cinquenta metros do veículo. Asseverou que foi realizado um cerco no imóvel. Disse que uma senhora saiu no segundo andar e conversou com os policiais. Aduziu que ninguém desceu. Relatou que somente depois de uma hora o réu saiu do outro lado da residência. Afirmou que o réu autorizou a entrada em sua residência. Sustentou que na oportunidade foi acionado o sinal sonoro do celular, o que permitiu a sua localização do lado de fora, junto a um muro, num terreno, com a carteira. Salientou que dentro da residência, também, foi encontrado um tênis cor azul, que foi mencionado pelas vítimas do roubo. Aduziu que foi encontrado, também dentro da casa, um outro celular, da marca Sony. Asseverou que o acusado conduziu os policiais até o veículo Spin. Aduziu que no interior do veículo foram encontrados o relógio de pulso e a pulseira de prata. Narrou que o acusado não soube esclarecer a propriedade dos objetos encontrados. Disse que no veículo também foi encontrado uma blusa, que foi reconhecida pelas vítimas do roubo. Relatou que o acusado, na delegacia, se comportou de forma

agressiva. Salientou que o Iphone foi encontrado no muro do lado de fora do imóvel. Reiterou que o celular Sony estava no interior do imóvel".

A testemunha Jorge Luiz do Prado, ouvido sob o crivo do contraditório, asseverou que " é o proprietário do imóvel, onde as vítimas estavam. Aduziu que passou pelo imóvel e viu o portão aberto. Disse que pretendia alertar as vítimas sobre o portão aberto. Salientou que uma pessoa saiu da casa com uma arma. Aduziu que aquela pessoa gritou dizendo que estava acontecendo um assalto. Disse que nem chegou a descer do carro. Notou que havia uma carro branco nas imediações, parado na outra rua, em uma esquina. Aduziu que não viu as características do assaltante, só ouviu a voz. Disse que estava escuro. Disse que voltou ao local e soube dos fatos por narrativas das vítimas".

Máximus Vinicius de Oliveira Silva, testemunha arrolada pela defesa, ouvida sob o crivo do contraditório, afirmou que " conhecia o réu. Disse que o réu outrora lhe cedeu o fundo de sua casa, para usar como " lava-rápido". Asseverou que nada sabia sobre os fatos. Aduziu que o tênis azul encontrado pela polícia era de sua propriedade. Disse que a família do acusado não tinha as chaves do " lava-rápido". Disse que não procurou o tênis depois da apreensão. Salientou que não possuía a nota fiscal do tênis. Sustentou que morava no local onde funcionava o " lava-rápido". Disse que não estava presente quando a polícia chegou. Disse que o acusado trabalhava com o aplicativo UBER, mas nunca usou seus serviços. Aduziu que não sabia informar se ele era cadastrado".

A companheira do acusado, Cláudia Cristina Alves de Paula, ouvida em juízo, afirmou que " tomou conhecimento dos fatos por intermédio do acusado. Narrou que o acusado disse que pegou dois indivíduos próximo da rodoviária de Aparecida e os levou para Guaratinguetá. Disse que, em Guaratinguetá, os indivíduos disseram para o seu companheiro esperar. Afirmou que o seu marido não sabia o que tais indivíduos iriam fazer. Segundo seu companheiro, alguns minutos depois, os rapazes retornaram e voltaram para Aparecida, deixando-os próximo de uma passarela. Disse que o réu chegou em casa muito nervoso. Salientou que os indivíduos fizeram ameaças de morte a ele e a sua família. Afirmou que a polícia não achou nada dentro da casa. Asseverou que o par de tênis encontrado não pertencia ao acusado. Salientou que o tênis foi encontrado na parte de baixo, que era alugado para um rapaz. Sustentou que a família não tinha as chaves do local, mas autorizou os policiais a cortarem o cadeado. Disse que o acusado trabalhava de Uber, mas não era cadastrado. Afirmou que algumas pessoas ligavam para o seu numero de celular, para fazer corridas e outras paravam na rua. Aduziu que o acusado trabalhava com o UBER desde o inicio da pandemia, mas não era habilitado. Asseverou que comprou o veículo e é habilitada".

Como se vê, a prova dos autos é firme e coesa no sentido de ser o acusado é o autor do crime descrito na denúncia.

Os depoimentos das vítimas e demais testemunhas foram precisos, detalhados e se complementaram.

No entanto, diante das circunstâncias (estava escuro e os assaltantes usavam blusas de moletom com capuz) em que os fatos ocorreram, as vítimas e a testemunha Jorge, não conseguiram ver a feição dos roubadores.

As vítimas, no entanto, reconheceram o par de tênis, apreendido pelos policiais, na casa do acusado, bem como a blusa de moletom encontrado no veículo Spin, utilizado pelo acusado para a prática do roubo.

É de se ressaltar, que o veículo Spin branco, que antes do assalto passou duas vezes na rua do imóvel onde as vítimas foram assaltadas, também foi reconhecido pelas vítimas e também pela testemunha Jorge.

Aliado tudo isso, o que demonstra a robustez da prova contra o acusado, esta a apreensão , em poder dele, de todos os objetos subtraídos das vítimas, exceto o dinheiro em espécie pertencente a vítima Rafael.

Note-se que o aparelho de celular Iphone e a carteira da vítima Thiago foram apreendidos próximo ao muro, ao lado da casa do acusado, ao passo que o aparelho celular, marca Sony, pertencente à vítima Rafael, foi apreendido no interior da residência do réu.

Ressalte-se que o acusado, com exceção da justificativa, não crível, apresentada

durante seu interrogatório, não conseguiu explicar, de forma aceitável, a posse dos objetos.

Não se pode olvidar que o acusado, juntamente com o seu comparsa, conforme declararam as vítimas, também tinha a intenção de levar o carro delas. Tanto isso é verdade que em poder do acusado foi encontrado a chave do carro que as vítimas estavam utilizando no momento do roubo (auto de apreensão de fls. 11/12 e auto de entrega de fls. 17/18).

Como se vê, não há a menor dúvida de que todos os objetos furtados, exceto certa quantia em dinheiro, foram encontrados em poder do acusado.

Logo, a sua versão sobre os fatos além de inverídica, restou isolada no conjunto probatório.

As testemunhas do rol defensivo, como sempre acontece, vieram a juízo, com o firme propósito de tornar dúbia, a prova amealhada para os autos. Elas nada presenciaram. Por outro lado, o próprio acusado confirma que esteve na cena do crime, mas tenta convencer de que agiu na condição de motorista de aplicativo (Uber), sob ameaças de dois indivíduos armados.

No entanto, a versão apresentada pelo réu, diante das circunstâncias em que ocorreram os fatos e o modo como foram realizadas as apreensões, mostra-se inverossímil, pois não é crível que roubadores, após obrigarem o acusado a trazê-los até Guaratinguetá, aguardar a ação criminosa e depois levá-los de volta até Aparecida, dando-lhes fuga, fossem esquecer todo o produto do roubo dentro do carro do réu.

Se não bastasse isso, o réu além não estar cadastrado no aplicativo (UBER), não era habilitado e o veículo não ostentava qualquer sinal indicativo de que era utilizado para transporte de passageiros.

De mais a mais, cabia a defesa comprovar a versão apresentada pelo acusado, conforme prevê o artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não aconteceu.

A negativa de autoria, no presente caso, foi devidamente desconstituída, conforme já mencionado, pelo conjunto probatório trazido para os autos. Se não bastasse isso, no presente caso o acusado foi encontrado na posse de res furtiva.

A jurisprudência é tranquila, no sentido de que a apreensão da res furtiva em poder do agente, gera a presunção da prática do delito, invertendo-se o ônus da prova.

Neste sentido:

"Roubo Majorado-Conjunto probatório desfavorável ao réu, lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais-Apreensão da res em poder do acusado-Inversão do ônus probatório-Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo- (...)Pondere-se ainda que a apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem". (TJSP; Apelação Criminal 1500577-64. 2019. 8.26. 0477; Relator (a) Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Praia Grande- 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento 28/01/2021; Data do Registro : 28/01/2021).

Destarte, verifica-se que a versão apresentada pelo acusado, diante da prova amealhada para os autos, além de inverídica, sequer foi comprovada pela defesa. Por outro lado, os elementos probatórios colhidos nos autos (reconhecimento do veículo pelas vítimas, trajes utilizado um dos autores, ou seja, moletom e tênis e apreensão da res furtiva em poder do acusado), confirma que o acusado foi um dos autores do roubo.

Deve ser levado em conta as versões apresentadas pelas vítimas, que sequer conheciam os acusados.

Neste sentido:

"ROUBO - Palavra das vítimas - Valor Probante: 90(b) - Em delitos de roubo, de regra não testemunhados, as palavras das vítimas, se uniformes e coerentes, são elementos seguros de convencimento, principalmente se não há dúvidas no reconhecimento". (RJDTACRIM. VOLUME 20. OUTUBRO/DEZEMBRO/1993 PÁGINA: 165 RELATOR: - ABREU MACHADO) "PROVA - Roubo - Palavra da vítima - Valor: 78 - Em sede do delito de roubo, a palavra da vítima é suficiente para ensejar o reconhecimento das qualificadoras do uso de arma e concurso de agentes, vez que possui grande valor probante por não conter ressaibo de vingança, a não ser o desejo de recuperar os

seus pertences subtraídos, concretizando a verdadeira justiça". (RJDTACRIM. VOLUME 20 OUTUBRO/DEZEMBRO/1993 PÁGINA: 149 RELATOR: - THYRSO SILVA).

"CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - Palavra da vítima - Valor probante: 114 - Em sede de crimes patrimoniais, os quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido". (RJDTACRIM. VOLUME 18. ABRIL/JUNHO/1993 PÁGINA: 194 RELATOR: - ORLANDO BASTOS)

Destarte, indubitável a autoria delitiva.

As causas de aumento de pena, ou seja, concurso de pessoas e uso de arma de fogo, ficaram devidamente comprovadas nos autos.

Por outro lado, a causa de aumento de pena referente a restrição da liberdade das vítimas, não deve ser reconhecida, visto que a ação do acusado e de seu comparsa foi muito rápida.

Assim, comprovadas a autoria, a materialidade e inexistindo causa de exclusão da ilicitude, a ação penal é procedente, não merecendo prosperar a tese defensiva de falta de prova, pois como já exaustivamente analisado, a prova dos autos é firma e coesa no sentido de ser o réu o autor do delito descrito na denúncia.

CUIDO DAS SANÇÕES.

Consoante as normas dos artigos 59 e 68 do Código Penal, verifico que o réu, ostenta condenações anteriores (fls. 206/215), as quais foram extintas há mais de cinco anos, possuindo, portanto, maus antecedentes, devendo as penas-base serem fixadas acima do mínimo legal.

Assim, fixo as penas bases acima do mínimo legal, ou seja, a pena privativa de liberdade em QUATRO (04) ANOS E OITO (08) MESES de reclusão e a pena pecuniária em DOZE (12) dias-multa, no mínimo legal.

Não constato a existência de agravantes e atenuantes.

Pelo concurso de agentes elevo a pena em 1/3 e pelo uso de arma de fogo elevo a pena em 2/3, passando assim a penas base para DOZE (12) ANOS, CINCO (05) MESES E DEZ (10) DIAS DE RECLUSÃO e ao pagamento de VINTE E SEIS (26) DIAS- MULTA.

E não há que se falar em aplicação de apenas uma causa de aumento de pena, se ambas as circunstâncias são graves, devem ser coibidas, não podendo uma delas passar a ser tomada como absolutamente irrelevante na dosagem da pena, sobretudo se o legislador, no mesmo tipo penal, fixou ambas as causas distintamente.

Ademais, por hipótese, caso se entenda em recurso de forma diversa, não podendo o concurso de agentes ser considerado absolutamente irrelevante, fica então considerado o aumento a ele correspondente como sendo circunstância judicial desfavorável, implicando em aumento da pena no mesmo montante na primeira fase da dosimetria.

Houve concurso de crimes, motivo pelo qual deve ser aplicado o disposto no artigo 70 do C.P., elevando-se as penas em 1/6, totalizando a pena privativa de liberdade em QUATORZE (14) ANOS E SEIS (06) MESES DE RECLUSÃO e a pena pecuniária em TRINTA (30) DIAS-MULTA, no mínimo legal, com correção monetária partir do fato.

Não havendo outras causas de alteração das penas bases torno-as definitivas.

Nos termos do Artigo 1º da Lei 12.736/2012, o tempo de prisão provisória deverá ser detraído da pena acima aplicada.

No entanto, deixo de aplicar o parágrafo 2º do artigo 387 do CPP, acrescido pela Lei 12.736/2012, por entender que tal disposição é inconstitucional, uma vez que viola o princípio da individualização da pena.

Aliás, a Lei de Execuções Penais, prevê diretrizes a serem observadas no momento da individualização da pena na fase executória.

Segundo o artigo 112 da LEP, para que o condenado possa ser beneficiado com a progressão de regime além de ter cumprido determinado quantum de pena, deve apresentar mérito, ou seja, bom comportamento carcerário.

Assim não se mostra possível a concessão de regime mais brando de cumprimento de pena aos réus, na sentença, sem a efetivação da avaliação de caráter subjetivo imposto pela L.E.P.

Ressalte-se que L.E.P é norma especial, devendo prevalecer sobre o Código de

Processo Penal, que é norma de caráter geral, mormente porque atende ao princípio Constitucional de Individualização das Penas em sua fase executiva.

Tendo em vista a gravidade do crime praticado, bem como por ainda estarem presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva, o acusado iniciará o cumprimento da pena em regime fechado e não poderá recorrer em liberdade, pois assim permaneceram durante todo o curso do processo.

Não se pode olvidar que as circunstâncias do cometimento do delito denotam uma maior reprovabilidade da conduta e justificam a imposição de regime prisional mais severo para o início da execução. O crime foi perpetrado em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, sem temor de haver represálias.

Confira-se, a propósito:

Superior Tribunal de Justiça (STJ): "In casu, o regime mais gravoso fundamentou-se na gravidade concreta do delito, em que os pacientes, condenados por roubo majorado apenas pelo concurso de agentes, 'simulando o porte de arma de fogo, abordam casal em plena via pública, para subtrair seus pertences' (fl. 66). Habeas corpus não conhecido (Habeas Corpus 391.494/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer (1109), Julg. 18.5.2017).

ISTO POSTO e considerando mais o que os autos consta, julgo PROCEDENTE a presente ação penal movida pela Justiça Pública para declarar o acusados VANDERLEY LUIZ PONCIANO Luiz Ponciano, como incursos nas penas do Artigo 157, §2º, inciso II (concurso de agentes) e §2º-A, I (emprego de arma de fogo), combinado com o artigo 70 "caput", todos do Código Penal e, em consequência, CONDENA-LO a pena privativa de liberdade, que fixo em QUATORZE (14) ANOS E SEIS (06) MESES DE RECLUSÃO e ao pagamento da pena pecuniária que fixo em TRINTA (30) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária a partir do fato.

Nos termos do artigo 1º da Lei 12.736/2012, o tempo de prisão provisória deverá ser detraído da pena acima aplicada.

No entanto, deixo de aplicar o parágrafo 2º do artigo 387 do CPP, acrescido pela Lei 12.736/2012, por entender que tal disposição é inconstitucional, uma vez que viola o princípio da individualização da pena.

Aliás, a Lei de Execuções Penais, prevê diretrizes a serem observadas no momento da individualização da pena na fase executória. Segundo o artigo 112 da LEP, para que o condenado possa ser beneficiado com a progressão de regime além de ter cumprido determinado quantum de pena, deve apresentar mérito, ou seja, bom comportamento carcerário.

Assim não se mostra possível a concessão de regime mais brando de cumprimento de pena aos réus, na sentença, sem a efetivação da avaliação de caráter subjetivo imposto pela LEP. Ressalte-se que LEP é norma especial, devendo prevalecer sobre o Código de Processo Penal, que é norma de caráter geral, mormente porque atende ao Princípio Constitucional de Individualização das Penas em sua fase executiva.

Tendo em vista a gravidade do crime praticado, bem como ainda estarem presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva, o acusado iniciará o cumprimento da pena em regime fechado e não poderá recorrer em liberdade, face a gravidade do crime.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO.

Por força do artigo 4º, parágrafo 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003,condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESP's, salvo em caso de gratuidade judiciária.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e façam-se as devidas comunicações.

P.R.I.C.

Walter Emídio da Silva

Juiz de Direito